

1501672-47.2021.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501672-47.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314819/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 21474174 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3583/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2314819 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

MATHEUS AMORIM DE SOUZA

Data da Audiência:

28/06/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 28 de junho de 2022, às 14 horas, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Alexandre Petry Helena - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, MATHEUS AMORIM DE SOUZA (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Flaviane de Oliveira Bertoline, OAB 205280/SP e Paulo Barbujani Franco, OAB 250176/SP. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Carlos Modesto Júnior e Antônio Carlos Anastácio Xisto. Presentes as testemunhas da defesa, a saber: José Afonso de Souza, João Carlos de Souza, Daniel Ribeiro Ornelas, Antônio Ricardo Rangel Esteves e Herick Henrique da Silva Martins.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Carlos Modesto Júnior e Antônio Carlos Anastácio Xisto, a seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas da defesa, José Afonso de Souza e Herick Henrique da Silva Martins, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva das testemunhas João Carlos de Souza, Daniel Ribeiro Ornelas e Antônio Ricardo Rangel Esteves. Na sequência, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Homologo a desistência da Defesa quanto à oitiva das testemunhas João Carlos de Souza, Daniel Ribeiro Ornelas e Antônio Ricardo Rangel Esteves. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação, absolvendo-se o réu da imputação do delito 16 da Lei 10.826/2003, mantendo-se, no mais, os exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. MATHEUS AMORIM DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e 35, da Lei nº. 11.343/2006, e nos artigos 12 e 16, ambos, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, supostamente, em data incerta, porém, anteriormente ao dia 18 de novembro de 2021 até a referida data, associou-se com as pessoas identificadas como “quebrada” e “neblina” para o fim de praticarem, ainda que não reiteradamente o delito de tráfico de drogas. Consta ainda que no dia 18 de novembro de 2021, às 19:20 horas, na Rua Antônio Henrique de Mesquita, nº 340, Casa Branca/Delfim Verde Capricórnio, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, o acusado, guardava e tinha em depósito 11 (onze) tijolos de Maconha, com peso total de 4.064g; 01 (um) Lança-Perfume, com peso total de 1.000ml; e 70 (setenta) pedras de Crack, com peso total de 26,78g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Por fim, consta que, nas mesmas condições de tempo e lugar, foi encontrada na posse de MATHEUS AMORIM DE SOUZA 01 (uma) munição de fuzil, CBC 12, de uso restrito, e 01 (uma) espingarda calibre 28, número 9785, de uso permitido, com 04 (quatro) cartuchos deflagrados de calibre 20, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 68/71). O réu foi citado (fl.126) e apresentou resposta à acusação (fls.89/122). Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, testemunhas de defesa, bem como o interrogatório do réu. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A materialidade está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição e apreensão (fls.16/17), auto de constatação preliminar (fl.18), laudos periciais (fls.188/192, 193/198 e 199/202) e demais provas produzidas nos autos. A autoria está comprovada. A testemunha e Policial Militar CARLOS MODESTO JUNIOR, disse, na delegacia, que se encontrava em ponto de estacionamento no bairro Casa Branca, momento em que receberam denúncia de um popular que não quis se identificar, noticiando que, em data anterior, o increpado havia ameaçado outras pessoas com uma espingarda, afirmando que ele estava em frente a uma casa próxima ao mercado Capital, no mesmo bairro. De imediato, a equipe policial solicitou apoio para deslocamento ao citado local, ponto conhecido de venda de drogas na comarca. No local, ao notar a incursão policial, o conduzido demonstrou nervosismo exagerado, e entrou correndo para o interior do imóvel, deixando o portão de acesso aberto. Assim, ante a fundada suspeita acerca da posse irregular da arma de fogo, foram ao seu encalço e, na sala do imóvel, foi localizada uma espingarda, desmuniada, bem como um (01) tablete de

maconha, momento em que o sujeito foi identificado como MATHEUS AMORIM DE SOUZA. Em revista ao imóvel foram localizadas facas e diversos apetrechos para fracionamento e acondicionamento da substância entorpecente, tais como balança de precisão e rolos de plástico filme. Indagado sobre a arma, informalmente, MATHEUS disse que somente possuía tal armamento, exibindo cartuchos vazios e um cartucho de fuzil, intacto. Declarou, também, que a arma era para sua defesa, pois ele é o responsável para abastecer a biqueira do bairro Canta Galo. Na ocasião, o increpado relatou que, próximo ao ponto de droga localizado citado no bairro, havia mais drogas enterradas. De pronto, foi feita busca ao local onde foram encontrados alguns tijolos de maconha e algumas pedras de crack, estas devidamente fracionadas e embaladas para a imediata difusão, no ponto de drogas do bairro do Canta Galo. Diante dos fatos, o depoente e seu colega de farda conduziram MATHEUS para esta delegacia juntamente com os entorpecentes e objetos encontrados. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e Policial Militar ANTONIO CARLOS ANASTACIO XISTO, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento semelhante ao de seu colega de farda, corroborando para sua versão. A testemunha de defesa JOSÉ AFONSO DE SOUZA, em Juízo, disse que é amigo dos pais do réu. Foi surpreendido pela prisão do réu. Pelo que sabe o réu é um menino estudioso e trabalhador. A testemunha de defesa HERICK HENRIQUE DA SILVA MARTINS, em Juízo, disse que sabia que o réu era usuário de drogas. Por também ser usuário de maconha, sabia que o acusado usava maconha. Jogavam no mesmo time de basquete. Em seu interrogatório, na fase policial, o réu MATHEUS AMORIM DE SOUZA, confessou os fatos. Disse que "realmente ganha valor para guardar e entregar entorpecente. Sobre a arma alega que é para sua defesa. Esclarece que mora no local a mais ou menos um ano e meio, sendo que conhece indivíduo de codinome "Quebrada" e um outro de codinome "Neblina". Esclarece que estava em sua casa quando ali surgiram policiais e que estes indagaram se o interrogado tinha armamento, e que mostrou a espingarda que tinha, mas que esta estava desmuniada. As munições estavam vazias, mas que era para carregar depois. "O cartucho de fuzil foi presente e que eu gosto de colecionar" sic. "A arma não sei se tem número, eu comprei para minha defesa pessoal" sic. "Realmente eu mostrei a arma para os desconhecidos a dois dias atrás e eles saíram correndo, acho que por isso a polícia foi ali" sic. Eles (policiais) perguntaram da droga e eu falei, mas eles me prometeram que eu ia ficar solto". "eu indiquei a mata onde estava escondida, porque sou eu quem recebo e escondo, e que o "Quebrada" que me leva, e um outro rapaz vai buscar uma vez por semana lá comigo, o tal de "neblina". "Não sei onde eles moram". "O quebrada pede para eu descer a droga lá em baixo e eu sei que é para abastecer o "Canta Galo", bairro. "Eu ganho duzentos reais para fazer esse movimento". Em Juízo, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que é usuário. Indicou o local onde era o ponto de drogas no mato porque comprava drogas neste local. Tinha a arma para a sua defesa, achou que não tinha problema. Comprou por R\$ 50,00 na feira do rolo. Quanto as munições, as encontrou no chão e pegou a munição para fazer um colar. Achou que não teria problema em ter esta arma na casa. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Isto porque, as declarações dos policiais foram firmes e coesas tanto em sede policial quanto em juízo, além disso as demais provas produzidas nos autos demonstram a autoria delitiva. As denúncias anônimas, a dinâmica da abordagem, a forma de acondicionamento, a quantidade e variedade de entorpecentes e o comportamento do acusado logo antes da abordagem denota que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilegal. Afasto a alegação de inobservância da inviolabilidade de domicílio do acusado. Isto porque, a partir dos relatos dos policiais tanto em sede policial quanto em juízo, infere-se que estes adentraram à residência do acusado pautados por fundadas razões que levavam a presumir a configuração de flagrante delito. Isto porque, o acusado se portou de maneira suspeita ao visualizar a guarnição, além disso, há haviam recebido denúncias indicando que o réu estaria em posse de arma de fogo no local. Ressalte-se que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). V - Do contrário, devidamente analisado o pleito na origem, o eventual acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido". (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020); TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO - RECURSO DEFENSIVO: PROVA ILÍCITA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - CRIME

PERMANENTE – HIPÓTESE EM QUE O AGENTE PERMANECE EM ESTADO DE FLAGRANTE ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA – SITUAÇÃO, ADEMAIS, EM QUE A CONDUTA ANTERIOR DO RÉU JUSTIFICOU A AÇÃO POLICIAL EM SUA MORADIA – PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500362-31.2021.8.26.0441; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/06/2022; Data de Registro: 13/06/2022, grifei) Assim, pautado por tais entendimentos jurisprudenciais, afasto a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, mormente levando-se em consideração que, de fato, o acusado estava em posse de grande quantidade de entorpecentes e arma de fogo no interior da residência vistoriada. No mais, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim “(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347). Cediço, ainda, que não há impedimento de que o usuário seja também traficante. Ainda que ficasse provada, a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08). Quanto à prova oral, consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer. Vejamos: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, o depoimento deles “podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte”. (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011). Ainda, vale ressaltar que eventuais pequenas incongruências nas declarações são compreensíveis dado o decurso do tempo entre a abordagem policial e a realização desta audiência, contudo não são capazes de retirar a credibilidade dos testemunhos dos policiais militares. Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). Por outro lado, quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há

como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a respaldar uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018). E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré."(STF - HC: 124164

AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014). Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial". (TJSP; Apelação Criminal 0000021- 93.2019.8.26.0556; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021); "REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel. Ingresso na residência autorizado pela corré, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo rime de associação ao tráfico de drogas à corré". (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021). Destarte, seguindo tais orientações jurisprudenciais, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre o réu e os demais indivíduos citados na denúncia. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe. Em relação aos delitos previstos

na Lei nº 10.826/03 a denúncia descreve que foram apreendidos em poder do acusado 01 (uma) munição de fuzil, CBC 12, de uso restrito, e 01 (uma) espingarda calibre 28, número 9785, de uso permitido, com 04 (quatro) cartuchos deflagrados de calibre 20. Assim, o Ministério Público imputou ao acusado os crimes descritos nos artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03. O laudo pericial acostado às fls. 193/198 indica que "A arma descrita, no estado em que foi apresentada para a Perícia, apresentava condições técnicas para atuar com eficácia na realização de disparos, podendo causar lesões perfuro-contusas quando carregada com munições compatíveis. A munição foi usada no teste e não apresentou funcionamento, constatando-se assim a ineficácia desta munição quanto à sua potencialidade lesiva". Não se olvida que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o delito de posse de arma ou munição de uso restrito é de perigo abstrato: "os delitos de porte de arma e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida" (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017), Não obstante, considerando que a munição não apresentava potencialidade lesiva bem como não foi apreendida arma de fogo compatível ao uso do artefato, entendo que a conduta foi absolutamente inócua, não apresentando potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. Nesse sentido: "Tráfico de drogas e posse de munições de uso restrito - Preliminar - Alegação de invasão de domicílio - Improcedente - Elementos que configuravam fundada suspeita de situação de flagrância apta a justificar o ingresso dos policiais na residência do réu - Mérito - Munições desacompanhadas de arma compatível - Absolvição por atipicidade - Ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado - Condenação mantida quanto ao crime de tráfico - Unissonos depoimentos policiais, apreensão de contabilidade do tráfico e frágil negativa do réu - Dosimetria - Não motivada a escolha de fração exasperante superior à mínima - Redução do aumento da pena-base - Reincidência que pode ser usada para agravar a pena e obstar a incidência do redutor do tráfico - Ausência de bis in idem - Precedentes - Preliminar rejeitada e recurso a que se dá parcial provimento". (TJSP; Apelação Criminal 1501431-07.2021.8.26.0536; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022, grifei). Assim, diante da constatação da potencialidade lesiva tão somente em relação à arma de fogo, de rigor a condenação apenas pelo delito descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, vez que a munição de uso restrito não possuía potencialidade lesiva. Destarte, afastando as teses apresentadas pela defesa, é de rigor a procedência parcial do pedido com a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e delito art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena, atendendo ao método trifásico da dosimetria. Fixo a pena para os delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/803. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade e variedade de drogas, elevo a pena em 1/5. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 01 ano de detenção, além de 10 dias-multa, para o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/803. Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea somente quanto ao crime previsto no 12, caput, da Lei nº 10.826/2003. Não obstante, considerando que as penas já se encontram no mínimo, inviável reduzi-las nesta etapa, nos termos do que preceitua a súmula nº 231 do C. STJ. Assim, mantenho as penas inalteradas nesta etapa. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena. Considerando a vultosa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como a apreensão de uma espingarda e munições, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige

que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A QUANTIDADE, A VARIEDADE E A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS SÃO CRITÉRIOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, JUSTIFICANDO O NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA". (STJ, AgRg no HC 590.092, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 06.10.2020). Sendo assim, torno definitivas as penas de 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 01 ano de detenção, além de 10 dias-multa, para o delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/803. Considerando a incidência do concurso material, opero a somatória das penas a fim de atingir a sanção final de 06 anos de reclusão, 01 ano de detenção, além de 610 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo regime FECHADO para a pena de reclusão e SEMIABERTO para a pena de detenção, tendo em vista a pena fixada e a gravidade em concreto dos delitos praticados, que consistia na venda de diversos tipos de entorpecentes, além de posse ilegal de arma de fogo. Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu MATHEUS AMORIM DE SOUZA, à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial FECHADO, 01 ano de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, além de 610 dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. Por fim, ABSOLVO o acusado da prática dos crimes previstos no artigo 35 da Lei 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Ressalte-se que a prisão cautelar do réu visa à manutenção da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta do acusado. Destarte, nego o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória. DECRETO O PERDIMENTO dos objetos e valores apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad; VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas

de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS.
Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a
impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através
do seguinte endereço eletrônico:

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/
Eu18DURt82FBol9RhyVb2VkBwo6IS0AB5c1dJkb8XD8zeQ?e=6hC1ds](https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/Eu18DURt82FBol9RhyVb2VkBwo6IS0AB5c1dJkb8XD8zeQ?e=6hC1ds)